

1500588-16.2020.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... a um contexto que leve a tratar de tráfico de drogas, a exemplo do infrator ser apreendido com instrumentos de corte e preparação da droga, portar balança de precisão, possuir condenação anterior por tráfico de drogas, entre outros. Não podendo chegar ao afastamento do porte para consumo pessoal e conclusão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Carmo, Araraquara - SP - cep 14801-425

INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500588-16.2020.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2309442/2020 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Luis Alves da Silva

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 06 de abril de 2022, na 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, presentes a(o) Excelentíssima(o) Sr(a). Dr(a). Adriana Albergueti Albano, MM. Juiz(a) de Direito, a(o) representante do Ministério Público, Dra. Patrícia Sguerra Vita e Castro, o(a) réu(ré) Leonardo Luis Alves da Silva, acompanhado(a) pelos advogados constituídos, Dr. Paulo Valili Neto, OAB/SP 208188 e Cláudio Diógenes Luiz, OAB/SP 444859.

Excepcionalmente, esta audiência será realizada por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Iniciados os trabalhos, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) PM Adriano Luis Dias e PM Diego Teixeira Leite, além do que foi o réu interrogado, tudo pelo sistema de gravação (Microsoft Teams). O conteúdo da gravação será inserido no sistema SAJ, conforme certidão que à frente segue. Pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Após, não havendo mais provas a serem produzidas, pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que dava por encerrada a instrução processual.

O Ministério Público apresentou as alegações finais oralmente.

A Defesa apresentou a seguinte manifestação por escrito: "Meritíssima Juíza, cumpre ressaltar que a Lei n.11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário, pequeno, médio ou grande traficante. À doutrina ficou a tarefa de oferecer elementos explicativos e distintivos entre o tráfico de drogas e o porte para consumo pessoal, bem como o ônus da prova. Assim, pacificou-se que, muito embora o tipo penal dos referidos delitos não faça essa distinção, a caracterização para consumo pessoal, quando ínfima a quantidade da droga apreendida com o infrator, só pode ser afastada se somado a um contexto que leve a tratar de

tráfico de drogas, a exemplo do infrator ser apreendido com instrumentos de corte e preparação da droga, portar balança de precisão, possuir condenação anterior por tráfico de drogas, entre outros. Não podendo chegar ao afastamento do porte para consumo pessoal e conclusão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, baseando-se exclusivamente na localidade em que o delito foi praticado ou a suposta presunção de que esse estaria em atividade suspeita. Nesse sentido, manifesta Nucci: "Essa situação não comporta resolução teórica única, pois depende do caso concreto e das provas produzidas em cada processo. Porém, tem sido referencial para a jurisprudência brasileira a quantidade de droga apreendida, os antecedentes criminais do agente, quando voltados ao tráfico, bem como a busca do caráter de mercancia. Quem traz consigo grande quantidade, já foi condenado anteriormente por tráfico e está em busca de comercialização do entorpecente é, com imensa probabilidade, traficante. No entanto, aquele que possui pequena quantidade, nunca foi antes condenado por delito relativo a tóxicos, bem como não está comercializando a droga é, provavelmente, um usuário." (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - Guilherme de Souza Nucci - 2º edição revista, atualizada e ampliada - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007 - p.318). No presente caso Excelência, é possível fazer tais análises, uma vez que a quantidade de droga apreendida (82,06 gramas - fls.15), variedade (apenas maconha, fls. 78/79), não é expressiva e este foi o entendimento do STJ ao analisar o caso em questão no julgamento do HABEAS CORPUS Nº 640803 - SP (2021/0017948-0), onde o Excelentíssimo Ministro Relator NEFI CORDEIRO, tece as seguintes considerações: "No entanto, ao analisar as circunstâncias do caso, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva, tratando-se, na hipótese, de 82,06 gramas de maconha." (fls. 130/131) No depoimento dos Policiais, ambos esclareceram que não encontraram dinheiro, balança ou anotações junto ao acusado. Com base nas declarações e provas documentais acostadas ao presente processo, é perfeitamente possível verificar a ausência de qualquer evidência que confirme as alegações do Ministério Público. Afinal, não há provas que sustentem as alegações trazidas no processo, sequer indícios contundentes foram juntados à inicial. Leonardo, em seu interrogatório negou de forma veemente o tráfico de drogas, disse que é usuário da substância maconha, por esse motivo estava portando. Não existe nenhum indicativo da comercialização. O Ministério Público não comprovou que a destinação seria para o tráfico, nada existindo nos autos, devendo o caso ser desclassificado para o artigo 28 da Lei 11.3343/06. Excelência, diante da pequena quantidade apreendida (82,6g), somada à ausência de provas suficientes da traficância e ao interrogatório de Leonardo, que nega a prática do crime de tráfico, resta provado que o mesmo é apenas usuário. Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11343/2006; reconhecimento da figura privilegiada; substituição da pena carcerária por restritiva de direitos; abrandamento do regime prisional - Pleito absolutório inatendível. Comprovadas autoria e materialidade. Cabível a desclassificação para o delito do art. 28. Réu admitiu a posse para consumo próprio. Circunstâncias não demonstram que a destinação das drogas era a comercialização. Policiais não presenciaram atos de mercancia. Pena. Advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06 - Recurso provido, em parte, para desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, nos termos do v. Acórdão. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado." (TJ-SP - APR: 15002490820198260616 SP 1500249-08.2019.8.26.0616, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 29/01/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/01/2021). Com os fatos narrados até o presente momento, pode ser observado que Leonardo não cometeu qualquer ilícito de traficância, mas tão somente o de ser usuário e não saber conter seu vício, não praticando a comercialização de drogas. Mesmo que estivesse com essa ínfima quantidade de entorpecentes, como afirmou o membro acusatório, que era para venda, porque estaria trafegando com sua moto e não estava parado na tentativa de oferecer o produto como vendedor. Não há, portanto, outra circunstância que se somada fazem presumir a traficância, mas isoladamente o encontro casuístico das

drogas em local periférico, justamente com um usuário contumaz, sem qualquer outra prova em concurso que induzisse presunção de traficância. Cabe ainda salientar que, a única prova oral produzida contra Leonardo é duvidosa, em vista das presunções dos policiais, que não permitem alcançar a certeza razoável e necessária para a condenação pelo tráfico. Com base nos fatos narrados acima, está claro que o delito de tráfico ilícito de drogas deve ser desclassificado para o delito de uso.

Verificando a situação de Leonardo, é possível concluir que o mesmo é primário, na verdadeira acepção jurídica do termo; possui bons antecedentes; possui residência fixa; trabalhador e não integra qualquer organização criminosa. Logo Leonardo faz jus a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, do CPP fixando no mínimo legal. Portanto Excelência, requer a desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06; Subsidiariamente, requer a fixação da pena no patamar mínimo legal e que seja aplicado o benefício do artigo 33, §4º, do CPP, em seu patamar máximo, substituindo a pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direito; A fixação do regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade."

Pela(o) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Processo nº1500588-16.2020.8.26.0556. VISTOS. LEONARDO LUÍS ALVES DA SILVA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em síntese, segundo a denúncia, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta de 17h50, na Rua Maurício Galli, 500, Jardim Primor, nesta cidade e comarca de Araraquara, o indiciado LEONARDO LUÍS ALVES DA SILVA, qualificado a fls. 4, 15 e 21, trazia consigo e transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 51 invólucros plásticos do tipo ziplock acondicionando maconha, com peso líquido total de 82,06 gramas, tratando-se de substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 8, laudo de constatação provisória de fls. 12/14 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 78/79). Segundo se apurou, na ocasião, policiais militares, em atividade de patrulhamento com motocicletas pelo local dos fatos, se depararam com o indiciado trafegando em sentido contrário com o motociclo Honda/CG 125FAN, cor preta, placas DNX0C45-São Carlos/SP, indivíduo que já vinha sendo surpreendido em atitude suspeita em locais conhecidos como ponto de tráfico, razão pela qual deliberaram pela abordagem. O denunciado, ao notar que seria abordado, se evadiu arremessando ao solo um pacote durante a fuga, sendo perseguido e detido. Em seguida, um dos policiais retornou ao lugar onde o imputado havia dispensado referido objeto, em cujo interior foram encontradas e apreendidas cinquenta e uma porções de maconha. Na delegacia de polícia, inquirido a respeito, o increpado se declarou usuário de maconha alegando que a droga apreendida era destinada ao consumo pessoal (fls. 4). Dessa forma, as condições da abordagem, com a prisão em flagrante do increpado após a fuga na posse de vultosa quantidade de droga, excedente ao consumo pessoal e acondicionada pronta para o varejo, são circunstâncias a evidenciar que o entorpecente apreendido era destinado ao comércio espúrio. O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fls. 01) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 06/07). Auto de exibição e apreensão do entorpecente (fls. 08). FA e certidões (fls. 28/30). Laudo pericial do entorpecente (fls. 78/79). Em decisão (fls. 50/56), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Em decisão (fls. 88/89), foi recebida a denúncia. Defesa prévia (fls. 90/94). Em decisão do Superior Tribunal de Justiça (fls. 128/131), foi concedida liminar de "Habeas Corpus" para deferir a liberdade provisória ao acusado, determinando a expedição de alvará de soltura. Auto de incineração do entorpecente (fls. 152). O réu foi citado (fls. 131). Resposta à acusação (fls. 135/138). Em despacho (fls. 153), foi designada a presente audiência. Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Adriano Luís Dias e Diego Teixeira Leite. O réu foi interrogado. Em debates, a d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, ante a comprovação da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu. Os policiais asseveraram que o réu confessou que estava transportando a droga de um bairro para outro, mas não disse quem era o destinatário. A alegação do réu de que o entorpecente era destinado ao

seu consumo não vinga, pois dissonante das provas dos autos. O réu apresentou versões dissonantes. Requereu a fixação da pena acima do mínimo legal, considerando a quantidade da droga. Leonardo já era visto transitando em locais conhecidos como pontos de venda de droga. Requereu a fixação da pena acima do mínimo legal. O i. Defensor do réu a improcedência da ação, ante a fragilidade da prova produzida. Não há prova segura de que o réu estivesse praticado o tráfico. Ele era visto em pontos de droga, porque era usuário. O réu portava a quantidade de droga, para não precisar voltar em biqueiras. Subsidiariamente, requereu a descCLASSIFICAÇÃO para o delito de posse de entorpecente. As porções que foram apreendidas não pertenciam ao réu, que estava usando crack no local. Na hipótese de eventual condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas; a fixação do regime menos gravoso para o cumprimento da pena, no caso o aberto ou o semiaberto, caso em que deverá operar-se a detração; a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, facultando-se ao réu o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e Decido. A presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva restou provada através boletim de ocorrência (fls. 06/07). Auto de exibição e apreensão do entorpecente (fls. 08). FA e certidões (fls. 28/30). Laudo pericial do entorpecente (fls. 78/79), bem como declarações das testemunhas. A autoria do delito deve ser imputada ao réu. DAS TESTEMUNHAS. Ouvida no inquérito policial (fls. 02), a testemunha ADRIANO LUÍS DIAS disse que: faz parte do patrulhamento com motocicletas da polícia militar e juntamente com seu colega de trabalho estavam transitando nos local dos fatos quando o indiciado veio sem sentido contrário também dirigindo uma motocicleta; que o depoente percebeu que uma manifestação suspeita do indiciado e por isso decidiu abordá-lo; que o indiciado ao perceber que seria abordado iniciou fuga e no caminho jogou um pacote que estava consigo e continuou a fuga; que o depoente juntamente com seu colega de trabalho alcançaram o indiciado e enquanto seu colega o detinha, o depoente retornou para ver o que havia no pacote; que encontrou dentro dele cinquenta e uma porções de drogas; que essa conduta indicava que o indiciado vendia drogas, e nos policiamentos o indiciado sempre é notado em atitude suspeita em lugares que aparenta a venda desses produtos ilícitos. Ouvida no inquérito policial, (fls. 03), a testemunha DIEGO TEIXEIRA LEITE disse que: estava patrulhando cidade com motocicleta quando juntamente com seu colega de trabalho avistou o indiciado vindo em sentido contrário; que notou a atitude suspeita do indiciado e que logo mudou seu veículo de sentido; que o depoente e seu colega foram atrás dele e o indiciado jogou para longe de si uma pacote e continuou em transito demonstrando fuga; que naquele momento já se dava ordem policial de parada, mas o indiciado não atendia; que o indiciado foi alcançado e enquanto o depoente o mantinha detido, seu colega retorno para ver o que existia no pacote; que ali foi encontrada droga semelhante a maconha dividida em 51 papélotes; que foi dada voz de prisão ao indiciado. Inquirida em juízo, a testemunha ADRIANO LUÍS DIAS e DIEGO TEIXEIRA LEITE disse que em patrulhamento pela Avenida Maurício Galli, avistaram um indivíduo trafegando com uma motocicleta, no contrafluxo, na altura da Rua Edson Bacarim, onde o mesmo convergiu no sentido do bairro Selmi Dei. O réu demonstrou nervosismo e começou a mexer na cintura, o fez com que os policiais suspeitassem que pudesse estar armado. No percurso o réu dispensou qual dispensou um volume contendo maconha. Dada ordem de parada, com o réu nada foi encontrado. O policial voltou ao local onde foi encontrada a sacolinha contendo 51 porções de droga. O réu disse apenas que estava transportando a droga do bairro São Rafael, para o Selmi Dei, mas não falou o nome de ninguém. O PM Adriano não abordou o réu anteriormente, mas o viu em outros pontos de venda de droga. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA. Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 04), o réu LEONARDO LUÍS ALVES DA SILVA disse que: ÉUSUÁRIO DE MACONHA E ADQUIRIU AS DROGAS ENCONTRADAS PARA CONSUMO PESSOAL;QUE NÃO ESTAVA VENDENDO OU OFERECENDO AS DROGAS; QUE NÃO FUGIU DA POLÍCIA, MASLOGO QUE FOI DETERMINADO QUE PARASSE OBEDECEU E SE SUBMETEU AO PROCEDIMENTOPOLICIAL. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. Interrogado em juízo, o réu LEONARDO LUÍS ALVES DA SILVA disse que é viciado em maconha. No dia dos fatos pegou a droga no Jardim São Rafael e estava levando para a casa da sua mãe, para seu

consumo. Ao que se recorda, pagou a importância de R\$ 130,00. O réu usava bastante droga naquela ocasião. Esta foi a prova colhida durante a fase judicial, satisfatória para a procedência da ação penal. Com efeito. A autoria do delito descrito na denúncia deve ser atribuída ao réu. A alegação do réu de que a droga era destinada ao seu consumo, não é compatível com a sua condição pessoal. Além do mais, o réu afirmou que estava transportando a droga de um bairro para outro, sem identificar o remetente e o destinatário. Neste caso, as declarações dos policiais militares devem ser aceitas sem restrições, vez que o próprio acusado confessou a prática do delito. Ademais, não se pode desprestigiar os depoimentos dos policiais, sob o exclusivo argumento de serem policiais. Nesse sentido: "Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento policial. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer o seu testemunho pelas penas pela natureza de função que exerce, a par de não se ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto, preconceituoso e desarrazoado do atestado de inidoneidade de toda uma corporação" (RT 721/414). No mesmo sentido (RT 727/473, 709/369, 728/520, 723/583, 715/439 e 714/349). "A quantidade e a maneira como estava embalada a droga revela que o entorpecente era destinado ao tráfico. A alegação do réu de que a droga era destinada ao seu consumo, não se comprovou. O fato de o réu consumir entorpecente, não o exime da responsabilidade pelo tráfico. A quantidade de droga não era inexpressiva. O bairro situa-se na

periferia da cidade, onde o tráfico reveste-se de tais características, ou seja, os traficantes não costumam manter consigo grande quantidade de droga. No mais, os laudos toxicológicos afirmam a presença das substâncias entorpecentes no material apreendido. Portanto, os indícios veementes da prática do ilícito são suficientes para sua comprovação. Neste sentido: "É desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12 da Lei n. 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nela os autos" (TJSP, Rev. Crim. 261.898-3/2, 1º Gr. Câmara, j. 10-4-2000, rel. Des. Egydio de Carvalho, RT 779/554). E, ainda: "Para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente" (TJSP, ApCrim. 170.977-3, 3ª Câmara Crim., j. 31-10-1994, rel. Des. Segurado Braz, JTJ 165/334). Diante deste contexto, a condenação é medida de rigor. Réu primário, conforme FA e certidões (fls. 25/26 e 27/28). Passo a fixar a pena. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, não sendo ao réu totalmente desfavoráveis as condições genéricas, nem excessiva a quantidade de entorpecente apreendida, fixo a pena base no mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea que não têm o condão de minorar a pena inicial abaixo do mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes, pena inicial mantida nesse segundo estágio. Está presente a causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo de 2/3 (dois terços) a pena aplicada, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias multa. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado LEONARDO LUIS ALVES DA SILVA, devidamente qualificado, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", c.c. 4º, do mesmo artigo, da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias multa, fixado, cada um deles, no mínimo legal - 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data, tendo em vista, principalmente, a situação econômica do réu. De acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em

atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código. Considerando a pena imposta faculto o apelo em liberdade. Decreto a perda do dinheiro apreendido com o réu, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e sua combinação com os artigos 4º da Lei 7.650/86, 1º, parágrafo único, da Lei 8.257/91, inciso II, letra "b", do Código Penal, obedecendo-se, ainda, ao disposto no artigo 63 e seus parágrafos da Lei 11.343/06. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se. Arcará o réu com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Publicada em audiência. Comunique-se e intime-se. Saem intimadas as partes presentes. Nada mais."

Este termo é assinado eletronicamente pela(o) MM. Juiz(a), sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Eu, Estela Maris de Almeida, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.